

1500494-61.2021.8.26.0062

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164054/2021 - DEL.POL.BARIRI, 18553505 - DEL.POL.BARIRI, 750/21/202 - DEL.POL.BARIRI, 2164054 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SIMONE DE FATIMA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500494-61.2021.8.26.0062 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500494-61.2021.8.26.0062

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164054/2021 - DEL.POL.BARIRI, 18553505 - DEL.POL.BARIRI, 750/21/202 - DEL.POL.BARIRI, 2164054 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SIMONE DE FATIMA PEREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra SIMONE DE FÁTIMA PEREIRA, dando-a como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática, em tese, dos seguintes fatos, assim descritos na inicial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de junho de 2021, por volta das 9h30, na Avenida Antônio de Tamará, nº 100, praça Joseane, Núcleo II, nesta cidade e comarca de Bariri/SP, SIMONE DE FÁTIMA PEREIRA, qualificada às

fls. 25/28, trazia consigo, para fins de tráfico de droga, 24 (vinte e quatro) microtubos contendo cocaína, com peso bruto de 13,31 (treze gramas e trinta e uma decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/15; auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 16/17 e rebatimentos fotográficos às fls. 23/24 e laudo pericial às fls. 88/91).

Segundo se apurou, no dia dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram a investigada caminhando na Praça da escola Josiane Bianco, conhecido ponto de tráfico de drogas em Bariri, mantendo consigo uma bolsa a tiracolo do lado esquerdo. Ao seu lado direito, um rapaz de bicicleta parecia acompanhá-la, sendo que ambos mudaram o passo ao verem a aproximação da viatura. Ocorre que o rapaz ficou mais agitado e a investigada segurou mais firme a bolsa junto ao seu corpo. Desta forma, os policiais militares resolveram realizar abordagem.

Na sequência, o rapaz de bicicleta empreendeu fuga e a investigada, nervosa, disse que referido rapaz havia colgado algo em sua bolsa, muito embora os policiais não tivessem visto eles compartilharem nada.

No interior da bolsa da investigada os policiais militares encontraram um saco plástico, em cujo interior havia os vinte e quatro microtubos contendo cocaína. Ainda, lograram apreender um telefone celular e a quantia de R\$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais).

Assim, o comércio ilícito de entorpecentes praticado pela investigada se infere pela narrativa dos policiais militares que perceberem a atitude suspeita da indiciada e pelas condições em que se desenvolveu a ação, bem como pela enorme quantidade de drogas apreendidas.

Houve a prisão em flagrante da ré, convertida liberdade provisória com medidas cautelares (fls. 47/51).

Defesa prévia às fls. 131/148.

Às fls. 163/166, foi recebida a denúncia.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, interrogada o ré.

Em alegações finais mediante memoriais (fls. 426/428), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

A Defesa, em alegações finais por memoriais (fls. 433/438), pugnou, em resumo, no mesmo sentido que a acusação; subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/06), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fl. 17/18), laudo preliminar de entorpecentes (fls. 19/20), laudo médico (fl. 23) alvará de soltura (fls. 54/55), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 91/94) laudo pericial do aparelho telefônico (fl. 233), relatório investigativo (fl. 393), corroborada pela prova oral coligida, que adiante será exposta.

Com relação à autoria, a ré Simone de Fátima Pereira, interrogada em juízo, declarou que veio à cidade de Bariri-SP para receber o auxílio emergencial. Como era usuária de cocaína, foi buscar drogas para consumo. Comprava as drogas em Bariri-SP e não em Boracéia-SP, pois tinha medo de seus filhos tomarem conhecimento. Trabalha como cuidadora. Na abordagem, o dinheiro que estava consigo

era referente ao auxílio emergencial. Não é traficante e sim usuária. Comprou a quantidade apreendida porque não sabia quando retornaria à cidade.

A testemunha Claudionor José da Silva, policial militar, declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento preventivo naquela localidade, por ser local conhecido pelo tráfico de drogas. O local era uma praça defronte a uma escola municipal. Na rua, possuía total visão dessa praça, avistando um indivíduo de bicicleta ao lado de uma mulher, ambos em movimento. A bolsa estava do lado esquerdo da ré. Em seguida, eles avistaram a viatura policial e demonstraram nervosismo. O indivíduo que estava na bicicleta empreendeu fuga antes que pudesse ser identificado. Simone foi abordada, ocasião em que segurava firmemente a alça da bolsa. Em revista na bolsa, foi encontrado um saco azul contendo porções de cocaína, e eppendorfs de cor amarela. Segundo ela, o indivíduo da bicicleta, mediante ameaça, havia colocado as drogas dentro de sua bolsa. Estava no local dos fatos em busca de uma área para chamar o mototáxi. Posteriormente, na delegacia e em conversa com o filho de Simone, ele contou que deixou sua genitora na área central da cidade e depois a perdeu de vista. Diante de todo o ocorrido, ela foi presa em flagrante por tráfico. Simone trazia consigo, ainda, a quantia de 265 reais em notas diversas. Não a conhecia anteriormente.

A testemunha Devair Rocha, policial militar, prestou depoimentos no mesmo sentido que a testemunha Claudionor.

Em juízo, a testemunha Thiago Aparecido Luciano Bonani, declarou que Simone trabalha como cuidadora e passa o dia cuidando de sua genitora, que sofre de Alzheimer. Simone presta trabalhos à família por período superior a dois anos, de segunda a sexta.

Como percebo, o conjunto de provas bem demonstra a autoria do fato descrito na denúncia, o qual, porém, não se amolda à tipificação contida na inicial acusatória. A prova oral aponta, com segurança, que os entorpecentes apreendidos eram destinados exclusivamente ao consumo pessoal da ré.

Ademais, analisadas as mensagens obtidas do aparelho celular da ré, o setor de investigações gerais (SIG), em seu relatório à fl. 416, consignou: “a maioria dos diálogos é com familiares, sem qualquer interesse para a investigação, que algumas conversas relacionadas a entorpecentes que constam no laudo, a indicada se manifesta sempre em efetuar compras de cocaína na cidade de Bariri-SP, onde concluímos tratar-se de usuária da referida droga”.

Nesse sentido, deve ser acolhido o pleito de desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 - deduzido tanto pelo órgão acusatório quanto pela Defesa -, uma vez que todas as circunstâncias indicam que os entorpecentes apreendidos eram pertencentes à ré e se destinavam unicamente ao seu uso próprio.

A esse respeito, cabe acrescentar, apenas por registro, que não há violação o princípio da mínima ofensividade em razão da vigência do art. 28 da LD, resultante da política de desencarceramento de usuários de drogas - tendo havido, portanto, descaracterização, e não descriminalização, tampouco despenalização.

Estabelecida essa premissa, impositivo o reconhecimento da detração penal analógica virtual, afastando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para análise de transação penal.

Como se sabe, a detração penal, em sentido estrito, ocorre quando o Juízo deduz da pena ou da medida de segurança aplicada ao réu o tempo que ele ficou preso antes do trânsito em julgado (prisão provisória ou administrativa) ou o tempo em que ficou internado em hospital de custódia (medida de segurança). É matéria que, em regra, respeita à Execução Penal.

Por outro lado, diz-se detração “analógica” porque o art. 28 não prevê pena privativa de liberdade, impondo ao intérprete a utilização da analogia para descontar o tempo em que o réu sofreu mitigação ao seu status libertatis em razão da imposição de medidas cautelares, mesmo o art. 28 não cominando pena de prisão. Diz-se “virtual”, ainda, porque é possível o desconto do tempo de aplicação de certas medidas cautelares mesmo sem se condenar o acusado, quando, no caso concreto, haja um exaurimento do interesse estatal na continuidade da persecução penal e aplicação de pena. Nessas hipóteses, autoriza-se o reconhecimento de seus efeitos mesmo não se tratando de execução penal.

O instituto da detração penal analógica virtual é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, já reconheceu o prévio exaurimento da pretensão punitiva e a falta de interesse na aplicação da pena em razão do cumprimento da medida cautelar extrema (prisão preventiva) de natureza mais gravosa que a própria pena aplicável ao crime, de modo a justificar a declaração da extinção de punibilidade. Nesse sentido, confirmam-se: STJ, REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, e STJ, HC 390.038/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06/02/2018.

No julgado referente ao HC 390.038/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018), por exemplo, consignou-se: “A decisão de extinção da punibilidade, na hipótese, aproxima-se muito mais do exaurimento do direito de exercício da pretensão punitiva como forma de reconhecimento, pelo Estado, da prática de coerção cautelar desproporcional no curso do processo – que culminou com a condenação por porte de substância entorpecente para consumo próprio – do que com o esgotamento de processo executivo pelo cumprimento de pena. (...)”.

Analisando o caso concreto destes autos, observo que a ré, posta em liberdade provisória por ocasião da análise da prisão em flagrante, cumpre medidas cautelares diversas da prisão desde 17/06/2021, dentre as quais o recolhimento domiciliar noturno, da partir das 22h, e nos dias de folga (alvará de soltura de fls. 61/63). Embora a ré não tenha sido presa preventivamente, é certo que a medida cautelar imposta concretizou severa restrição de seu status libertatis por expressivo período (mormente considerando a prolação da sentença nesta data - 02/08/2022). É dizer, a medida cautelar impôs, pela sua natureza, restrição mais severa do que qualquer uma das penas previstas abstratamente no art. 28 da LD.

Aliás, não se olvida que os Tribunais pátrios vêm admitindo a detração do período de recolhimento noturno da pena efetivamente imposta. Colhe-se da jurisprudência do STJ que, “embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. Portanto, se na medida cautelar de recolhimento noturno entende-se comprometido o status libertatis do acusado, com mais razão ainda deve ser aplicada a detração na medida cautelar de recolhimento de fim de semana e feriados, pois a restrição é efetiva, como se prisão fosse. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp n. 1.895.641/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021).

No mesmo sentido, embora a matéria ainda não esteja pacificada, cito precedentes deste E. TJSP:

“Agravo em Execução. Recurso da defesa. Pedido de retificação do cálculo de penas para que seja computada a detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Possibilidade. O período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. Precedentes do STJ. Decisão que comporta reparos. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0004045-48.2022.8.26.0496; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022)

“Agravo em execução – Pedido de detração – Possibilidade – Existência de lapso temporal para abatimento da execução – Recurso parcialmente acolhido. Detração do período de medida cautelar em que houve permanência obrigatória em domicílio – Possibilidade – Desnecessidade de monitoração eletrônica – Soma das horas de recolhimento para conversão em dias – Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0003834-64.2022.8.26.0996; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Dito tudo isso, veja-se que, nas alegações finais do Parquet, o órgão acusatório ofertou transação penal consistente em advertência (fls. 428). Entretanto, no curso da tramitação deste feito, a ré já cumpriu medida cautelar que, concretamente, implicou restrição mais expressiva, ao seu estatuto de liberdades pessoais, do que qualquer pena a ser aplicada no crime do art. 28 da LD (que estaria, efetivamente, exaurida, houvesse a aplicação da detração). Diante disso, não subsiste interesse ao Estado na manutenção da persecução penal contra a ré, nem mesmo sob a ótica da aplicação de instituto referente à justiça penal negociada. Logo, constatada a prática de coerção cautelar desproporcional no curso do processo, é de rigor a imediata extinção da punibilidade da acusada, pois não mais subsiste justa causa ou interesse processual para o prosseguimento do feito, com fundamento do artigo 109 da LEP.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e DESCLASSIFICO a conduta atribuída à acusada SIMONE DE FATIMA PEREIRA, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o artigo 28 da mesma Lei nº 11.343/06; bem como, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada, por aplicação da detração penal analógica virtual, pois qualquer pena aplicável estaria fatalmente cumprida, nem havendo justa causa ou interesse processual para o prosseguimento do feito, com fundamento do artigo 109 da LEP. Ante a improcedência, REVOGO as medidas cautelares fixadas em desfavor da parte ré. Expeça-se o necessário. Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Quanto ao aparelho celular apreendido, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP". Determino a restituição dos valores apreendidos à parte ré. Expeça-se certidão de honorários em favor em favor do Defensor Dativo, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública. Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do CPP), suspensa a exigibilidade, porquanto lhe concedo o benefício da justiça gratuita. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Bariri, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA